

三、妨害作证罪中的“他人”可以作广义理解，包括所有诉讼参与人

刑法对妨害作证罪“指使他人作伪证”中的“他人”没有作明确限制，若尝试限制“他人”法律内在含义的范围并不符合法律的形式逻辑，因而“他人”应当包括所有的诉讼参与人，即当事人和其他诉讼参与人，甚至是其他任何人，如指使根本不了解案件情况的人充当证人。因此同案犯也能够成为妨害作证犯罪对象中的“他人”。

编写人：江苏省淮安市中级人民法院 张帅

江苏省涟水县人民法院 朱剑

明知他人利用其提供的银行卡 从事信息网络犯罪，并配合刷脸、 提供验证码行为性质的认定

——赵某掩饰、隐瞒犯罪所得案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

黑龙江省嫩江市人民法院(2023)黑1183刑初41号刑事判决书

2. 案由：掩饰、隐瞒犯罪所得罪

【基本案情】

被告人赵某，大学文化。2022年5月，被告人赵某在网上结识“跑分”人员，通过聊天软件联络、交流并决定参与“跑分”。2022年5月23日，被告人赵某到福建省南平市建瓯市，将自己的2张银行卡提供给“跑分”团伙使用，

并提供刷脸、验证码帮助上游犯罪分子转移犯罪所得。2张银行卡的单项流入资金共计1125447.11元，其中涉及诈骗案共计17起，涉案资金846045元。案发后，被告人赵某被抓获到案，退赔全部涉案资金。

【案件焦点】

行为人明知他人利用其提供的银行卡从事信息网络犯罪，又到场配合刷脸、提供验证码帮助转移犯罪所得，是否可以认定为主观明知是犯罪所得而予以转移，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

【法院裁判要旨】

黑龙江省嫩江市人民法院经审理认为：被告人赵某明知是他人犯罪所得而予以转移，情节严重的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控成立。赵某本应靠自己的文化知识、专业技能去创造财富，却为获取不法利益而触碰法律红线，其行为与我国社会主义核心价值观相悖。被告人赵某通过提供银行卡并配合刷脸、提供验证码的方式，帮助上游犯罪分子转移犯罪所得，系从犯，依法减轻处罚。被告人赵某到案后如实供述自己的罪行，系坦白，且自愿认罪认罚，依法从轻处罚。被告人赵某退还全部赃款，酌定从轻处罚。据此，判决：被告人赵某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币5万元。

案件宣判后，判决已生效。

【法官后语】

《中华人民共和国刑法修正案(九)》新增的第二百八十七条之二设立了帮助信息网络犯罪活动罪，将网络帮助行为以独立的罪名进行处罚。司法实践中，该罪名在打击电信网络诈骗、网络赌博等犯罪上下游关联犯罪时被广泛适用。

实践中，帮助信息网络犯罪活动罪和掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪成为近两年的高发罪名，尤其对于行为人提供银行卡后又进行刷脸验证的案

件，在适用上存在诸多争议。帮助信息网络犯罪活动罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪在量刑的设置上有着很大不同，根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条帮助信息网络犯罪活动罪的法定刑设置，本罪的法定最高刑为三年，是一项轻罪，追诉标准为支付结算金额20万元以上，而掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的法定刑设有两档，三年以下有期徒刑和三年以上七年以下有期徒刑，第二档刑的追诉标准为涉案数额10万元以上。因此，正确区分两罪对于贯彻罪责刑相适应原则、统一法律适用具有重要意义。本案在审理过程中，存在两种截然不同的观点。

第一种观点认为，被告人赵某提供银行卡的转进与转出都是一种帮助行为而非隐瞒犯罪所得行为，帮助行为发生在上游犯罪实施过程中，即上游犯罪所实施的犯罪行为尚未获取赃款、赃物，不同于掩饰、隐瞒犯罪所得的事后帮助行为。因此，应构成帮助信息网络犯罪活动罪。

第二种观点认为，被告人赵某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍向他人提供银行卡，并在他人对卡内资金进行转移的过程中配合对方进行刷脸验证，该行为可视为参与对赃款的转移，应认定为掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。

笔者同意第二种观点，被告人赵某的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，且根据其在犯罪中所起的作用，认定为从犯。具体理由分析如下：

一、从主观是否明知为犯罪所得来分析

帮助信息网络犯罪活动罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的主观方面均为明知，但两者的主要区别在于，主观明知的内容不同，帮助信息网络犯罪活动罪的主观明知是一种概括性明知，即行为人只知对方可能实施网络违法犯罪行为，对被帮助对象的犯罪手段、性质等都不明确；而掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪要求明知涉案资金是上游犯罪的犯罪所得，既可以是概括明知，也可以是明确知晓。主观明知的具体内容，是区分支付结算型帮助信息网络犯罪活动罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的重要标准。

关于正确区分帮助信息网络犯罪活动罪和掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪与诈骗罪共犯的界限，即应当根据行为人的主观明知内容和实施的具体犯罪行为，确定其行为性质。行为人向他人出租、出售信用卡后，在明知是犯罪所得及其收益的情况下，又代为转账、套现、取现等，或者为配合他人转账、套现、取现而提供刷脸等验证服务的，可以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪论处。明知他人利用信息网络实施犯罪，仅向他人出租、出售信用卡，未实施其他行为，达到情节严重标准的，可以帮助信息网络犯罪活动罪论处。

上海市第一中级人民法院课题组在中国应用法学2022年第1期发表的《网络支付结算型帮助行为的刑法规制——兼论帮助信息网络犯罪活动罪的理解与适用》^①一文中指出，提供银行卡并转账的行为系在事后为犯罪分子隐瞒资金流向，既属于帮助行为，又妨害了司法秩序，在认定该类行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪还是帮助信息网络犯罪活动罪时，可以从以下角度考虑。其一，审查转账资金的性质，若转账资金非犯罪所得，如为赌资，则可以排除掩饰、隐瞒犯罪所得罪，以帮助信息网络犯罪活动罪定罪处罚；若转账资金为犯罪所得，则以掩饰、隐瞒犯罪所得罪处罚。其二，若转账资金无法全部查明性质，则能够查明上游犯罪事实部分，根据转账资金性质来认定相关罪名，对于无法查明上游犯罪事实的部分，以帮助信息网络犯罪活动罪定罪，然后在两罪中择一从重定罪处罚。

具体到本案中，赵某具有大学本科文化程度，对其转移的赃款明知程度不同于帮助信息网络犯罪活动罪的概括明知，从手机聊天记录亦能反映出其明知其参与的“跑分”就是转移赃款。赵某在联系到“跑分”团伙后主动前往福建省建瓯市参与“跑分”，并非仅仅提供、出卖银行卡，放任上游犯罪分子操作，而是在此基础上提供了刷脸和验证码的又一层次的帮助。赵某在实施行为前已与上游犯罪分子有联络，目的明确就是要参与“跑分”，其对银行卡内资金来

^①上海市第一中级人民法院课题组、上海市第一中级人民法院：《网络支付结算型帮助行为的刑法规制——兼论帮助信息网络犯罪活动罪的理解与适用》，载《中国应用法学》2022年第1期。

路不正是有认识的,对其行为是转移犯罪所得及其收益持放任态度,即主观上具有转移犯罪所得的故意,客观上确实属于犯罪所得及其收益,因此应认定其构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。实践中,上游犯罪为了防止“黑吃黑”,在行为人转账时会限制其人身自由,即使这样,为获取高额报酬,行为人自愿被“看管”,甚至跨省、市为上游转账,对于这些人仍然以帮助信息网络犯罪活动罪认定,罪责刑将明显不相适应,因此定掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪更为合适。

二、从行为时间节点来分析

帮助信息网络犯罪活动罪行为通常发生在上游犯罪着手之后尚未获取赃款赃物之前。而掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪则是典型的事后帮助犯罪,发生于上游犯罪既遂之后,即相应犯罪所得已经被上游犯罪分子控制。

就本案来看,被害人被诈骗的钱款在转账至赵某账户时,被害人已失去对钱款的支配能力,上游犯罪已经既遂,赵某提供刷脸和验证码的验证服务,帮助上游犯罪分子转移赃款,逃避司法追查,致使赃款无法追回。赵某的客观行为体现在以下两个方面:一是将银行卡提供给上游犯罪行为收取赃款;二是配合上游犯罪行为刷脸、提供验证码以转移赃款。尽管赵某提供银行卡时并不明确知道上游行为是何种性质的犯罪行为,但对他人向其银行卡转入的款项,其能够意识到属于上游犯罪的赃款,且资金转入其银行卡时上游犯罪已经既遂。通说认为,电信网络诈骗犯罪的既遂,并不要求必须亲手控制,对于电信网络诈骗团伙所控制的人或组织控制财物的,即可以认定为既遂。也就是说,当被告人来到现场被控制以后,电信网络诈骗资金转入其卡中,上游犯罪即既遂。在这之后,其只要参与了掩饰、转移赃款的,就应当认定为掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。

三、从被告人整体行为综合分析

本案中,赵某虽然存在明知他人利用信息网络实施犯罪,仍将银行卡提供给他人使用的帮助信息网络犯罪活动的行为,但其又持卡到犯罪分子从事具体犯罪活动的地点,配合刷脸、提供验证码,从一般人的常规认识和判断以及赵

某的文化程度来看，足以证明赵某主观上明知其帮助转移的系犯罪所得，此时以帮助信息网络犯罪活动罪定罪已不能全面评价其犯罪行为，且赵某掩饰、隐瞒犯罪所得金额80余万元已达情节严重的标准，故被告人的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。

综观全案，赵某提供银行卡帮助他人从事信息网络犯罪活动，其身份属性与帮助信息网络犯罪活动罪中的“卡农”较为相似，唯一不同的是赵某相较帮助信息网络犯罪活动罪中的“卡农”又提供了进一步的刷脸、提供验证码的帮助行为。众所周知，在登录网上银行或使用银行卡转账时，刷脸、提供验证码是比较常见的情形，操作上也比较简单，不具有技术性或专业性，明显属于辅助行为。因此笔者认为，无论从该种行为的具体性质来看还是从目前规范性文件的表述上来看，在认定帮助转移犯罪所得的“卡农”刑事责任时，除考虑掩饰、隐瞒犯罪所得的数额外，还应考虑其在犯罪过程中的地位作用。对于大多数“卡农”而言，其主要是协助、配合组织者转移赃款，在整个犯罪过程中起次要和辅助作用，依法可以认定为从犯。特别是在其掩饰、隐瞒犯罪所得数额达到量刑第二档时，根据其从犯的地位作用，依法从轻、减轻处罚，确保罪责刑相适应。

编写人：黑龙江省黑河市中级人民法院 余金玲